

1501721-27.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... flagrante na mesma Rua Ataíde pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e encontrava-se em liberdade provisória (autos 1501044-94.2021.8.26.0599).

Ademais, o próprio acusado admitiu que praticava o tráfico de drogas quando adolescente e no outro processo pelo qual está preso.

Considerando a dedicação do acusado a atividades criminosas, assim como a gravidade em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501721-27.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2304275/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21276713 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3182/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2304275 - 05º D.P. PIRACICABA,

3182/21/922 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 03 dias do mês de maio de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) GABRIEL JÚNIOR OLIVEIRA ALVES DA SILVA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, Anderson Correia e Rebeca Mirian Alves Braga. Ausente a testemunha Ruan Kayque dos Santos, não localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.171; ausente também a testemunha arrolada em comum pelas partes: Matheus Miguel dos Santos, o qual foi devidamente intimado e

informou que participaria presencialmente da audiência (fls.179), mas não o fez. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (Wanderson, Anderson, e Rebeca) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Pelo Promotor de Justiça foi dito que desiste da oitiva da testemunha Matheus Miguel dos Santos

Pela defensora foi dito que desiste da oitiva das testemunhas Ruan Kayque dos Santos e Matheus Miguel dos Santos.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência do M.P. (fls.177), e da Defesa na data de hoje, em relação à testemunha Ruan Kayque dos Santos.

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Matheus Miguel dos Santos na data de hoje. .

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, na Rua Raul Ataíde, número 161, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 20 (vinte e um) ''ependorfs'' contendo cocaína com o peso líquido aproximado de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado a fls. 124, o réu apresentou defesa prévia a fls. 131/134. A denúncia foi recebida a fls. 147/150. Na instrução o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese necessária.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 23/26 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 144/146.

A autoria do crime descrito na denúncia restou comprovada.

O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo relatou, na fase policial, que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se deparam com três indivíduos que, ao verem a viatura, saíram em desabalada carreira, em direção à padaria existente no local dos fatos. Que viram quando, ao entrar no estabelecimento, um dos suspeitos dispensou algo que trazia consigo em uma lixeira e, logo na sequência, entregou alguma coisa, aparentemente dinheiro, a uma mulher que estava na padaria e agarrou uma criança. Que, realizada a abordagem, com o indivíduo visto dispensando o objeto, posteriormente identificado como GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA ALVES DASILVA, foram localizados R\$ 50,00 e 01 (hum) 'pino' contendo aparentemente COCAÍNA. Que, após vistoria, foi constatado que aquilo que ele havia dispensado eram, na verdade, 19 porções de substância análoga à COCAÍNA. Que também restou apurado que a criança agarrada pelo indiciado era filha dele. Que, os outros dois indivíduos que estavam com GABRIEL também foram abordados, sendo identificados como o adolescente RUAN KAYQUE DOS SANTOS e como o maior MATHEUS MIGUEL DOS SANTOS. Que, com esse, foram encontrados R\$ 5,00 e também uma porção de substância semelhante à MACONHA. Que, já com aquele, 3 porções de substância similar à MACONHA, 1 invólucro plástico contendo aparentemente COCAÍNA e, ainda, R\$ 25,00. Que, por sua vez, com a mulher para quem GABRIEL teria entregado algo, identificada como REBECA, nada de ilícito foi localizado, apenas R\$

78,00. Que, ao ser abordada, REBECA os desacatou, chamando-os de "arrombados do caralho" e de "filhos da puta". Que, indagados, os suspeitos negaram a autoria delitiva, afirmando que eram simples usuários. Que, diante dos fatos, os agentes da Lei, após cientificarem o suspeito a respeito de seus direitos constitucionais, lhes deram voz de prisão em flagrante e os encaminharam a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas ante o fundado receio de fuga" (fls. 04/05).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva. Disse que, durante patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram três indivíduos que entraram em um comércio. O réu, na ocasião, dispensou algo em uma lixeira, entrou um objeto a uma moça e pegou uma criança no colo. Realizada a abordagem, encontraram, com o acusado, R\$ 50,00 e um pino de cocaína. Foram encontradas mais drogas com Matheus e Ruan, que estavam com o acusado. Foi encontrado dinheiro (R\$ 78,00), com Rebeca, que passou a hostilizar os policiais. Na lixeira, foram encontrados 19 pinos de cocaína idênticos ao encontrados com o acusado. Disse ter presenciado o momento em que o acusado jogou algo na lixeira, constatando-se, posteriormente, que se tratava das substâncias entorpecentes. Esta lixeira ficava do lado de fora do estabelecimento. Disse que Matheus e Ruan saíram correndo para o interior do comércio e não presenciou eles dispensando algo na lixeira. Disse que já conhecia o acusado de outras abordagens no bairro. Informou que "todo dia cai denúncia com as características dos indivíduos" que estavam no local. Afirmou que o saco plástico em que estavam as drogas estavam bem em cima da parte interior do lixo. O saco plástico até se abriu e parte dos entorpecentes foram para a parte de baixo, mas havia parte do lixo na parte superior.

Por sua vez, o policial militar Anderson Correia contou, na fase policial, que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina, conhecido ponto de venda de drogas, quando viram um trio de agentes saírem em desabalada carreira, em direção à padaria existente no local dos fatos, aparentemente tentando se evadir de eventual abordagem. Que, ao entrar no estabelecimento, um dos suspeitos dispensou algo que trazia consigo em uma lixeira e, logo na sequência, entregou alguma coisa, aparentemente dinheiro, a uma mulher que estava na padaria e agarrou uma criança. Que, realizada a abordagem, com o indivíduo visto dispensando o objeto, posteriormente identificado como GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA ALVES DA SILVA, foram localizados R\$ 50,00 e 01 (hum) 'pino' contendo aparentemente COCAÍNA. Que, após vistoria, foi constatado que aquilo que ele havia dispensado eram, na verdade, 19 porções de substância análoga à COCAÍNA. Que também restou apurado que a criança agarrada pelo indiciado era filha dele. Que, os outros dois indivíduos que estavam com GABRIEL também foram abordados, sendo identificados como o adolescente RUAN KAYQUE DOS SANTOS e como o maior MATHEUS MIGUEL DOS SANTOS. Que, com esse, foram encontrados R\$ 5,00 e também uma porção de substância semelhante à MACONHA. Que, já com aquele, 3 porções de substância similar à MACONHA, 1 invólucro plástico contendo aparentemente COCAÍNA e, ainda, R\$ 25,00. Que, por sua vez, com a mulher para quem GABRIEL teria entregado algo, identificada como REBECA, nada de ilícito foi localizado, apenas R\$ 78,00. Que todos os suspeitos foram abordados no interior da padaria. Que, ao ser abordada, REBECA os desacatou, chamando-os de "arrombados do caralho" e de "filhos da puta". Que, indagados, os suspeitos negaram a autoria delitiva, afirmando que eram simples usuários. Que, diante dos fatos, os agentes da Lei, após cientificarem o suspeito a respeito de seus direitos constitucionais, lhes deram voz de prisão em flagrante e os encaminharam a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas ante o fundado receio de fuga" (fls. 06).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia. Disse que o acusado, ao avistar a aproximação dos policiais, dispensou algo dentro de um cesto de lixo, entregou algo a sua companheira e segurou uma criança. Realizada a abordagem, encontraram, com o acusado, um pino de cocaína e mais R\$ 50,00. Também encontraram dinheiro fracionado com a companheira do acusado. Depois disso, no cesto de lixo em que o réu havia dispensado algo, encontraram mais 19 eppendorfs de cocaína, embaladas de forma idêntica à apreendida com o réu. Outras duas pessoas

estavam com o acusado, sendo encontradas mais drogas com tais indivíduos. Eles alegaram que eram usuários. A companheira do acusado passou a insultar os policiais na ocasião. Esclareceu que estes indivíduos entraram juntos no estabelecimento ao avistarem a polícia. O cesto de lixo em que o acusado dispensou os entorpecentes ficava fora do estabelecimento. O local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas. Disse que já abordou o acusado na mesma rua. Informou que havia denúncias específicas direcionadas ao acusado com sendo traficante de entorpecentes.

Matheus Miguel dos Santos relatou, na fase administrativa: "na data e horário dos acontecimentos, estava com o adolescente RUAN quando resolveram ingressar na padaria existente no local dos fatos para comprar alguns itens. Que, quando foram deixar o recinto, policiais militares que abordavam um outro homem do lado do fora do estabelecimento, os impediram de sair, dizendo que também seriam revistados. Que o homem abordado do lado de fora era o seu primo GABRIEL. Que não trazia consigo nenhum entorpecente, apenas R\$ 5,00. Que não viu seu primo GABRIEL em momento algum ingressar na padaria, tampouco se desfazer de qualquer objeto. Que é usuário de maconha" (fls. 07).

O adolescente Ruan Kayque dos Santos relatou, na fase policial: "na data e horário dos acontecimentos, estava com o investigado MATHEUS quando resolveram ingressar na padaria existente no local dos fatos para comprar alguns itens. Que, antes disso, estavam jogando bilhar em um outro estabelecimento. Que, quando foram deixar o recinto, policiais militares que abordavam um outro homem do lado do fora do estabelecimento, os impediram de sair, dizendo que também seriam revistados. Que trazia consigo apenas 4 porções de maconha, todas destinadas ao seu consumo pessoal. Que não viu o homem que era abordado do lado de fora da padaria, o ora indiciado GABRIEL, em momento algum ingressar na padaria, tampouco se desfazer de qualquer objeto. Que é usuário de maconha" (fls. 08).

Rebeca Mirian Alves Braga, esposa do denunciado, por sua vez, declarou, no inquisitório: "na data e horário dos acontecimentos, estava defronte à padaria existente no local dos fatos, na companhia de seu esposo, GABRIEL, e também de seu filho recém-nascido. Que, mesmo tendo a criança em seus braços, o seu esposo foi abordado pela PM. Que desconhece se ele trazia algum entorpecente consigo. Que, em momento algum, viu GABRIEL dispensar drogas na lixeira do estabelecimento. Que, durante a abordagem, de fato, chamou um dos policiais de arrombado, mas somente porque ele tomou o celular que tinha nas mãos e que usava para filmar a ação. Que não sabe dizer quem seria esse policial. Que o dinheiro que trazia consigo lhe foi dado, momentos antes, por GABRIEL, como pagamento da pensão devida ao filho do casal" (fls. 09).

Em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido de seus relatos na fase policial. Disse que era namorada do acusado, com o qual possui um filho que fará três anos. No dia dos fatos, o acusado havia a entregue uma nota de R\$ 100,00, para que o dinheiro fosse usado com seu filho. Depois disso, dirigiu-se à padaria, com seu filho e com o réu. Após, outros meninos entraram na padaria. Na sequência, os policiais entraram na padaria e pediram para o réu soltar seu filho. Os policiais, então, abordaram o acusado e outros dois meninos que estavam na padaria. Na ocasião, pegou seu celular para filmar, mas o aparelho foi retirado de suas mãos. Ficou nervosa e disse: "nossa que arrombado", razão pela qual foi puxada pelos policiais e colocada com os três meninos. Os policiais mexeram no lixo da padaria e passaram a procurar algo nas guias das calçadas. Pouco depois, foram algemados e colocados na viatura. Não viu os policiais encontrarem nada com Gabriel, Matheus e Rauan. O dinheiro que havia recebido de Gabriel foi apreendido. Também encontraram dinheiro com outro menino. Afirmou que não foi encontrada droga com Gabriel. Em frente à padaria, há um baldo de lixo que foi revistado pelos policiais. Notou que os policiais saíram com um "saquinho" deste lixo. Informou que o réu não trabalha e mora com a mãe. Conhece Matheus. Não conhece Ruan. Afirmou que Gabriel não jogou a sacola no lixo, mas confirmou que ele estava atrás dela quando entraram no estabelecimento comercial.

Os relatos de tais pessoas, nitidamente parciais e tendenciosos, devem ser analisados com sérias ressalvas e não afastam a credibilidade dos firmes e sólidos depoimentos prestados pelos policiais. Ora, Matheus é primo do acusado e Rebeca é

namorada e mãe do filho do réu, sendo Ruan pessoa próxima do indigitado, ficando clara a intenção de tais pessoas beneficiarem o acusado. É certo, ainda, que tais pessoas também possuem envolvimento com os fatos, tanto que respondem por outros delitos cometidos na mesma ocasião, razão pela qual sequer tinham compromisso de dizer a verdade.

Aliás, a vontade de beneficiar o acusado era tamanha que a namorada Rebeca não reconheceu sequer a apreensão da droga confessada pelo acusado.

O réu, interrogado no inquérito policial, alegou: "na data e horário dos acontecimentos, estava defronte à padaria existente no local dos fatos, na companhia de sua esposa, REBECA e também de seu filho recém-nascido. Que, mesmo tendo a criança em seus braços, foi abordado pela PM. Que trazia consigo apenas uma porção de MACONHA destinada ao seu uso pessoal. Que havia acabado de chegar no local, vindo da casa de sua sogra, que fica próximo dali. Que, pouco antes de ser abordado, viu seu primo MATHEUS e um outro homem entrarem na padaria. Que não acompanhou a abordagem a que foram submetidos. Que conhece apenas a pessoa de MATHEUS, que é seu primo. Que já foi preso anteriormente, por tráfico de drogas. Que, em tal oportunidade, tal como agora, também sofreu uma prisão forjada. Que o policial Azevedo, que participou da abordagem, o ameaçou de morte, dizendo que "a motinha iria passar"" (fls. 10/11).

Em juízo, tornou a negar a prática do crime. Admitiu, contudo, que os policiais encontraram 20 pinos de cocaína na lata de lixo. Ademais, confessou que efetivamente praticava o tráfico no processo pelo qual está preso, por fatos ocorrido no mesmo local.

A versão apresentada, contudo, não resiste aos demais elementos de prova colhidos. Dessa forma, encerrada a instrução, a imputação restou devidamente comprovada. No que tange à palavra dos policiais, importante observar que foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mormente pela apreensão da droga em poder do acusado, o que corrobora as informações recebidas pelos agentes. Portanto, merecem credibilidade os depoimentos dos policiais diante da coerência e harmonia com o restante do acervo probatório, além do que, sequer possuíam motivos para incriminá-lo.

Com efeito, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/64), de maneira que é "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372 e, no mesmo sentido, STRTJ 68/54).

Observo que, segundo os policiais militares, as drogas encontradas no lixo eram idênticas à porção apreendida com o réu e estavam na parte superior do cesto de lixo, ficando claro que os entorpecentes haviam acabado de ser dispensados, como dito pelos policiais.

Desse modo, considerada a quantidade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento da substância, e a confirmação da prova em juízo, indubitável que a droga se destinava à comercialização.

Assim, comprovadas materialidade e autoria delitivas a condenação é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena, a variedade e a natureza de entorpecentes (cocaína) devem ensejar a fixação da pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas não deve ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que o acusado se dedicava a atividades criminosas, tanto que foi preso em flagrante na mesma Rua Ataíde pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e encontrava-se em liberdade provisória (autos 1501044-94.2021.8.26.0599).

Ademais, o próprio acusado admitiu que praticava o tráfico de drogas quando adolescente e no outro processo pelo qual está preso.

Considerando a dedicação do acusado a atividades criminosas, assim como a gravidade

em concreto do crime, entendo que o regime prisional deve ser o fechado, sendo inviável a concessão de penas alternativas, pelo quantum da reprimenda e pela dedicação ao tráfico.

Requeiro, ainda, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, com fulcro nos artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, requer a procedência da ação nos sobreditos termos.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 108-110), no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 19h15, na Rua Raul Ataíde, número 161, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Gabriel trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 20 (vinte e um) eppendorfs contendo cocaína com o peso líquido aproximado de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e viram o réu e duas pessoas no local acima indicado, conhecido ponto de tráfico. Ao notarem a presença policial, iniciaram fuga em direção a uma padaria e Gabriel dispensou algo em uma lixeira, entregou um objeto a uma mulher que estava na padaria e agarrou-se a uma criança. Realizada a abordagem, os policiais encontraram com o réu um pino de cocaína e R\$50,00. Em seguida, recuperaram o objeto dispensado e constataram que se tratava de 19 (dezenove) porções de cocaína. Também foram abordadas as duas pessoas que correram junto com o réu. Com elas, o adolescente Ruan Kayque dos Santos e o imputável Matheus Miguel dos Santos, os policiais encontraram porções de maconha, um pino de cocaína e dinheiro. Com Rebeca Miriam Alves Braga, a mulher para quem o réu entregou algo, os policiais encontraram R\$78,00 (setenta e oito reais).

Interrogado em solo policial, o réu disse que: "na data e horário dos acontecimentos, estava defronte à padaria existente no local dos fatos, na companhia de sua esposa Rebeca e também de seu filho recém-nascido. Mesmo tendo a criança em seus braços, foi abordado pela PM. Trazia consigo apenas uma porção de maconha destinada ao seu uso pessoal. Havia acabado de chegar no local, vindo da casa de sua sogra, que fica próximo dali. Pouco antes de ser abordado, viu seu primo Matheus e um outro homem entrarem na padaria. Não acompanhou a abordagem a que foram submetidos. Conhece apenas a pessoa de Matheus, que é seu primo. Já foi preso anteriormente, por tráfico de drogas. Em tal oportunidade, tal como agora, também sofreu uma prisão forjada. O policial Azevedo, que participou da abordagem, o ameaçou de morte, dizendo que 'a motinha iria passar'" (fls. 10-11).

Matheus Miguel dos Santos contou que: "na data e horário dos acontecimentos, estava com o adolescente Ruan quando resolveram ingressar na padaria existente no local dos fatos para comprar alguns itens. Quando foram deixar o recinto, policiais militares que abordavam um outro homem do lado do fora do estabelecimento e os impediram de sair, dizendo que também seriam revistados. O homem abordado do lado de fora era o seu primo Gabriel. Não trazia consigo nenhum entorpecente, apenas R\$ 5,00. Não viu seu primo Gabriel em momento algum ingressar na padaria, tampouco se desfazer de qualquer objeto. É usuário de maconha" (fls. 7).

Ruan Kayque dos Santos relatou que: "na data e horário dos acontecimentos, estava com o investigado Matheus quando resolveram ingressar na padaria existente no local dos fatos para comprar alguns itens. Antes disso, estavam jogando bilhar em um outro estabelecimento. Quando foram deixar o recinto, policiais militares que abordavam um outro homem do lado do fora do estabelecimento e os impediram de sair, dizendo que também seriam revistados. Trazia consigo apenas 4 porções de maconha, todas destinadas ao seu consumo pessoal. Não viu o homem que foi abordado do lado de fora da padaria, o ora indiciado Gabriel, em momento algum ingressar na padaria, tampouco se desfazer de qualquer objeto. É usuário de maconha" (fls. 8).

Rebeca Miriam Alves Braga disse que: "na data e horário dos acontecimentos, estava defronte à padaria existente no local dos fatos, na companhia de seu esposo,

Gabriel, e também de seu filho recém-nascido. Mesmo tendo a criança em seus braços, o seu esposo foi abordado pela PM. Desconhece se ele trazia algum entorpecente consigo. Em momento algum, viu Gabriel dispensar drogas na lixeira do estabelecimento. Durante a abordagem, de fato, chamou um dos policiais de arrombado, mas somente porque ele tomou o celular que tinha nas mãos e que usava para filmar a ação. Não sabe dizer quem seria esse policial. O dinheiro que trazia consigo lhe foi dado, momentos antes, por Gabriel, como pagamento da pensão devida ao filho do casal" (fls. 9).

Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, policial militar, contou que: "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se deparam com três indivíduos que, ao verem a viatura, saíram em desabalada carreira, em direção à padaria existente no local dos fatos. Viram quando, ao entrar no estabelecimento, um dos suspeitos dispensou algo que trazia consigo em uma lixeira e, logo na sequência, entregou alguma coisa, aparentemente dinheiro, a uma mulher que estava na padaria e agarrou uma criança. Realizada a abordagem, com o indivíduo visto dispensando o objeto, posteriormente identificado como Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva, foram localizados R\$ 50,00 e 01 (hum) 'pino' contendo aparentemente cocaína. Após vistoria, foi constatado que aquilo que ele havia dispensado eram, na verdade, 19 porções de substância análoga à cocaína. Também restou apurado que a criança agarrada pelo indiciado era filha dele. Os outros dois indivíduos que estavam com Gabriel também foram abordados, sendo identificados como o adolescente Ruan Kayque dos Santos e como o maior Matheus Miguel dos Santos. Com esse, foram encontrados R\$ 5,00 e também uma porção de substância semelhante à maconha. Já com aquele, 3 porções de substância similar à maconha, 1 invólucro plástico contendo aparentemente cocaína e, ainda, R\$ 25,00. Por sua vez, com a mulher para quem Gabriel teria entregado algo, identificada como Rebeca, nada de ilícito foi localizado, apenas R\$ 78,00. Ao ser abordada, Rebeca os desacatou, chamando-os de 'arrombados do caralho' e de 'filhos da puta'. Indagados, os suspeitos negaram a autoria delitiva, afirmando que eram simples usuários [...]" (fls. 4-5).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Anderson Correia (fls. 6).

Às fls. 62-63, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19-20, laudo de constatação de fls. 23-26 e laudo de exame definitivo de fls. 144-146. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido, inicialmente, o policial militar Anderson Correia. Relatou que realizava patrulhamento na área dos fatos por ser local conhecido pela mercancia de drogas. Ao entrar na via, visualizaram alguns indivíduos que, ao perceberem a presença dos policiais, entraram no estabelecimento comercial (padaria/mercadinho). Enquanto caminhava em direção ao estabelecimento, um indivíduo descartou algo no lixo, deu algo a uma moça que depois souber ser sua namorada/companheira e pegou uma criança no colo. O tempo todo, davam voz de parada. A mulher xingava os policiais. Conseguiram abordar o rapaz e, com ele, encontraram 1 eppendorf de cocaína e R\$50,00. Com a mulher, localizaram mais uma quantia de dinheiro fracionado. Fizeram buscas no cesto de lixo e ali localizaram 19 eppendorfs iguais ao encontrado com o réu, também com cocaína. [E as outras duas pessoas avistadas conversando?] Também localizou entorpecentes. Com Mateus havia uma porção de maconha e R\$5,00; com o outro indivíduo, encontraram também droga e dinheiro. Ambos se disseram usuários. Os 3 entraram juntos na padaria. O cesto de lixo ficava em frente à padaria, do lado direito, perto da parede, na calçada. [O que Gabriel falou?] Disse que a droga no lixo não era dele e que a droga que tinha consigo era para uso próprio. A namorada disse que o dinheiro encontrado com ela era dela. [Conseguiu visualizar, quando Gabriel entregou algo à mulher, se era dinheiro?] Não, somente viu que entregou algo que não identificou e, depois, já abraçou a criança. [Viu Gabriel dispensando algo no lixo?] Sim. [Viu o que ele jogou no lixo?] Não. Conhecia

somente Gabriel, abordado antes na mesma rua. Não conhecia os demais envolvidos. Nunca encontrou objetos ilícitos no poder de Gabriel. [A droga encontrada no lixo estava na parte de cima?] Não sabe responder, pois foi o policial Azevedo que fez essa busca e pegou os objetos. [Teve conhecimento de outras abordagens ao réu no local?] Outros policiais lhe disseram que tinham recebido denúncias de que Gabriel traficava no local. Disse ter acompanhado todos os apreendidos andando em direção à padaria, seguindo pelo mesmo caminho, mas somente Gabriel teria se aproximado do cesto de lixo. Não conhece Ruan e desconhece denúncias de tráfico contra ele. Em seguida, ouvido o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo. Relatou que estava em patrulhamento no local dos fatos e avistaram 3 indivíduos que, ao avistarem a polícia, entrou em uma padaria, jogou algo na lixeira, deu algo a uma moça que estava dentro do estabelecimento e pegou uma criança no colo. Tentaram a abordagem e a população investiu contra eles. Chamaram reforço e conseguiram fazer as buscas. Com o réu, localizaram 1 pino de cocaína e 50 reais. Com Mateus havia 1 porção de maconha e 5 reais. Com o adolescente Ruan havia 25 reais, 3 porções de maconha e 1 pino de cocaína. Na lixeira havia 19 pinos de cocaína idênticos aos localizados tanto com Ruan quanto com Gabriel. Com a moça, que depois soube se chamar Rebeca, havia 78 reais. Acredita que foi isso que Gabriel entregou a ela. Rebeca disse que o dinheiro foi dado por Gabriel para ela para usar com a criança. [Visualizou o momento em que Gabriel dispensou algo na lixeira?] Sim. [Viu que era droga?] Não, só viu que era uma coisa. Com a confusão ("vucu-vucu"), tiveram que esperar o reforço para inspecionar a lixeira. A lixeira ficava do lado de fora, ao lado do comércio, antes de entrar. O local é uma mercearia, vende de tudo um pouco. [Os outros dois também se aproximaram da lixeira?] Somente viu Gabriel dispensando algo na lixeira; os outros dois, não viu. [O que Gabriel disse?] Não conseguiu falar muito porque a população estava exaltada. Tiveram que sair dali logo. Depois, no DP, Gabriel disse que as drogas não eram dele. Mateus e Ruan disseram que eram usuários. Já conhecia todos os abordados ali, exceto Rebeca, de outras abordagens. No local, todo dia tem denúncia de tráfico via COPOM "nas características dos meninos". Os meninos seriam Gabriel, Mateus e Ruan. [Já prendeu algum dos abordados em outra ocasião?] Não. [A droga estava onde no lixo?] Alguns pinos dentro de um saco, na parte de cima do lixo, outros caídos no fundo. Teve que tirar todo o lixo para pegar todos. [Onde os senhores ficaram esperando o reforço chegar?] Ficaram na porta, olhando para dentro e para fora, pois a população estava ali pressionando. [Ficaram dentro do local, aguardando o reforço chegar?] Não consegue dizer, pois foi uma situação muito tensa.

b) Na sequência, foi ouvida Rebeca Miriam Alves Braga. É ex-namorado do réu. Na época dos fatos, não estavam namorando com Gabriel. Têm um filho em comum, de 3 anos. Estava em frente de casa com Gabriel. Ele lhe deu R\$100,00 que tinha pedido já cedo, para comprar as coisas para o filho deles. O filho começou a pedir para ir à padaria. Pegou o dinheiro e foi à padaria. O filho e Gabriel foram juntos. Morava na Tv. Cosmorama. Comprou algumas coisas ao filho. Gabriel estava com o filho, atrás dela. Os 3 entraram juntos na padaria. Viu alguns meninos entrando na padaria. Logo depois, duas motos pararam e os policiais entraram na padaria. Eles vieram e mandaram Gabriel soltar o bebê. O filho não queria sair do colo do pai. Ela foi tentar pegar a criança, mas o policial já começou a enforçar Gabriel. Ela começou a gritar em desespero, e a tia, que mora em frente, veio em socorro. Conseguiu entregar a criança para a tia. Gabriel permanecia segurado pelo pescoço pelo policial, enforcando. Pegou o seu celular para filmar, mas um policial veio na sua frente e a questionou, impedindo a filmagem. Tomou o celular da sua mão. A mãe chegou, pediu para devolver o aparelho, mas ele disse que não, só depois da abordagem. Nervosa, falou "Nossa, que arrombado". O policial a pegou pelo braço, puxou e a colocou no meio dos outros 3 abordados (Gabriel e outros dois meninos que estraram na padaria). Os policiais revistaram os meninos, os "negócios" da padaria (lixo), começaram a procurar na rua, nas guias das calçadas. Os policiais ficaram conversando e, depois de alguns minutos, pegaram os 4, algemaram e colocaram dentro do carro. [O que os policiais encontraram?] Que a depoente viu, nada. Com Rebeca,

acharam o troco do dinheiro que tinha gastado na padaria. Acharam também o salgadinho do filho. Com um outro menino também encontraram dinheiro, mas não foi muito, acha que 20/25. Com Gabriel, que tenha visto, não tinha droga. Na hora que viu, em frente à padaria, na porta, tinha um balde de lixo com um saco preto. De lá, o policial tirou um saquinho, mas não sabe o que tinha. A casa que morava era quase ao lado da padaria, eram imóveis separados apenas por um barracão em que funciona uma igreja. Quando Gabriel chegou, já estava na frente de casa. [Com que Gabriel trabalha?] Ele mora com a mãe e é pensionista. Mateus mora próximo, não conhece o outro abordado. [O dinheiro entregue por Gabriel era pensão?] Todo dia 28, Gabriel pega dinheiro de pensão. O filho estava sem leite, por isso mandou mensagem pedindo dinheiro. Ele deu R\$100,00. Usou o dinheiro para comprar salgado? Sim, mas ele deu R\$100,00, dava para comprar leite e sobrava. [De quanto é essa pensão?] A mãe, irmão e Gabriel recebem essa pensão, mas outras pessoas trabalham na família. Não sabe se Gabriel usa ou vende trocas. Mais para baixo, é local de venda de drogas. Não viu Gabriel jogar nada no lixo. Gabriel entrou atrás dela com o filho, mas não era muito para trás, teria visto se ele tivesse se dirigido ao lixo. Depois, os policiais entraram e um monte de gente entrou na padaria também. Perguntada, explicou que vieram da sua casa, passaram pela igreja e entraram na padaria. O lixo fica do outro lado. O comércio tem duas portas, mas só uma fica aberta, grande. Não passaram pelo lixo. Depois que entraram, demorou uns minutos para a polícia chegar. Deu tempo de comprar o salgadinho para o filho, pagar e receber o troco. Quando levaram Mateus, demorou um pouco para a colocarem ao lado dele, não estava ali quando fizeram a primeira revista. Explicou que a pensão recebida por Gabriel e os familiares é a pensão por morte do pai de Gabriel, e a parte dele corresponde ao valor de aproximadamente 300 reais.

d) Por fim, foi interrogado o réu Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva. Estava trabalhando com catação de reciclagem. Ganhava por volta de R\$200,00 a quinzena. Também tinha a pensão por morte do pai, no valor de R\$300,00 - o restante do valor fica com a mãe. Sobre os fatos, disse que a droga não era sua. Azevedo o ameaçava desde que era adolescente, dizia que "a motinha ia passar e matá-lo". Estava na frente da casa de Rebeca com ela e o filho. O filho, Kevin, quis ir na padaria. Ela foi na padaria com Kevin e o depoente foi atrás. Os policiais encontraram os 20 pinos, mas com ela nada acharam. Quando os policiais chegaram, estava do lado de dentro da padaria com Rebeca e o filho. Os policiais começaram a "fuçar" e encontraram os 20 pinos no latão de lixo da padaria. Quanto a Ruan e Mateus, não sabe o que estavam fazendo. Eles estavam fora da padaria. Com o depoente, os policiais não encontraram nada ilícito. Tinha dado R\$100,00 para Rebeca. Só usa maconha, tinha consigo na abordagem. Não consegue ficar sem usar. Não tem envolvimento com o tráfico. Quando era adolescente, confirma que se envolveu com o tráfico. Conhecia os policiais. Tem algo contra Azevedo, pois ele o ameaçava. Sabe se encontraram droga com Ruan e Mateus? Sim. Eram usuários? Sim. É primo de Mateus; não conhece Ruan. Estava conversando com Mateus quando os policiais chegaram. Ruan estava perto, mais para trás. Entrou rápido na padaria quando os policiais chegaram? Não. Entrou na padaria porque Rebeca o chamou. Entregou o dinheiro depois que os policiais chegaram ou antes? Antes. Pegou o filho por quê? "Ser abordado, mesmo". Já cumpriu medida socioeducativa? Não. Foi preso antes e estava envolvido com o tráfico, mas tinha parado.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Conforme contou, é usuário de drogas. Tinha recebido a pensão por morte do pai. Entregou a Rebeca R\$100,00, para ajuda de custos do filho, e foram à padaria comprar o salgadinho que o filho pediu. Compraram, pagaram, Rebeca recebeu o troco. A polícia chegou depois.

O depoimento de Rebeca deixou claro que não passaram pelo lixo onde as demais drogas foram encontradas. Os outros abordados, Mateus e Ruan - que, mesmo intimados, não compareceram para depor, em atitude suspeita -, passaram pelo lixo,

e podem ter sido os responsáveis por esconder ali as drogas.

Além disso, os policiais, em seus depoimentos, indicaram que não vigiaram o lixo por todo o tempo antes de revistá-lo, podendo as drogas serem ali colocadas por terceiro enquanto aguardavam a chegada do reforço.

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydney de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Com o acusado foi localizado apenas uma porção de cocaína, característica do uso de entorpecentes confessado pelo réu.

Nas palavras da Eminentíssima Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista da Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a média de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa

Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve,

a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Da segunda-fase: atenuantes

Ainda que aumentada a pena-base, é certo que o acusado é menor de 21 anos, motivo pelo qual faz jus à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do CP.

Isso posto, a pena-base, se aumentada na primeira fase deve retornar ao mínimo legal.

c) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo. Processos em curso não são aptos a afastar o benefício e, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido